Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
5ª Vara Cível da Comarca de Caxias do Sul

Rua Dr. Montaury, 2107, 4° andar - Bairro: Exposição - CEP: 95020190 - Fone: (54) 3039-9081 - Email: frcaxsul5vciv@tjrs.jus.br

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 5023608-18.2021.8.21.0010/RS

AUTOR: DANIEL SCHARDONG (ESPÓLIO)

RÉU: UNIMED NORDESTE RS SOCIEDADE COOP DE SERV MEDICOS LTDA

SENTENÇA

Vistos etc.

DANIEL SCHARDONG (Espólio), qualificado na inicial, ajuizou ação de obrigação de fazer contra **UNIMED NORDESTE RS SOCIEDADE COOP DE SERV MÉDICOS LTDA.**, também qualificada.

Narrou ser portador de Linfoma não-Hodgkin difuso (CID C83), tendo efetuado o tratamento com R-CHOP, R-ICE, transplante eutólogo e radioterapia, refratório a todos os tratamentos. Disse que durante o mencionado tratamento, teve a cobertura do plano de saúde réu do qual é segurado por força do convênio médico da empresa em que laborava, conforme matrícula nº 00410010007273700. Todavia, recentemente teve negada, em 08/12/2020, a cobertura na utilização das medicações prescritas e justificadas pelo médico responsável pelo tratamento. Conforme atestado médico acostado, encontra-se com a patologia em atividade sendo necessária de forma urgente a nova terapia com a medicação Brentuximabe, 50mg, e Nivolumab, sendo que se não for ministrada com a máxima brevidade. Referiu que necessita de 4 (quatro) ciclos das medicações apontadas, das quais o médico prescreveu como necessários 5 frascos de 50g da medicação Brentuximabe e 2 frascos de 100g e 1 frasco de 40g ambos da medicação Nivolumab. Alegou que o tratamento médico é imprescindível à manutenção da sua vida, devendo o réu custear o referido tratamento mediante aquisição do medicamento prescrito, já que não possui condições financeiras de custear o altíssimo valor dos fármacos, cujo valor supera a importância de R$ 126.670,00. Invocou a incidência do CDC. Requereu a concessão da tutela para que a ré forneça os medicamentos (Brentuximabe Vedotina - 5 frascos/cxa de 50mg; Nivolumab - 2 frascos de 100mg; e Nivolumab - 1 frasco de 40mg); no caso de não haver o fornecimento dos fármacos pela ré, seja de imediato deferido o pedido em forma de pecúnia no valor de R$ 126.670,00. Postulou a concessão do benefício da AJG. Pediu a procedência da ação, para confirmar os efeitos da antecipação da tutela, e no mérito, determinando que a parte ré mantenha até quanto necessário e recomendado o tratamento na forma como prescrito na receita e laudo médico que acompanha a presente demanda. Atribuiu à ré os ônus sucumbenciais. Pediu a aplicação de multa para o caso de descumprimento da tutela antecipada. Deu à causa o valor de R$ 126.670,00. Juntou documentos - Evento 1.

Foi deferida a tutela antecipada, bem como o benefício da AJG - Evento 3.

Citada, a demandada contestou - Evento 11. Preliminarmente, impugnou o valor atribuído à causa. Esclareceu que o demandante é beneficiário de contrato de plano de na modalidade coletivo empresarial, regulamentado, o qual se submete, integralmente, às disposições da Lei dos Planos de Saúde (LPS), assim como às normas exaradas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Destacou que o artigo 10 da referida lei, é responsável por estabelecer as diretrizes mínimas do "plano referencial", é clara e expressa ao estabelecer a exclusão de cobertura para medicamentos experimentais. Destacou que a mesma disposição consta na Resolução Normativa 465/2021 da ANS, a qual inclusive esmiúça as espécies de tratamentos que são, tecnicamente, reputados como sendo de natureza experimental, dentre os quais enquadram-se os tratamentos off-label. Salientou que a exclusão consta no próprio contrato do qual o requerente é beneficiário, tal qual expressamente redigido na Cláusula 9ª, III. Referiu que a solicitação de autorização foi recepcionada na via administrativa e submetida à apreciação da Auditoria Técnica da requerida, que, após analise – especialmente considerando o caso do autor – concluiu pela natureza experimental do tratamento postulado, por ser off-label. Mencionou que os medicamentos (Brentuximabe e Nivolumab), são indicados, conforme informação do próprio fabricante, para tratamentos distintos da patologia que acomete o autor. Alegou a inexistência de abusividade e da Taxatividade do Rol da ANS. Impugnou a inversão do ônus da prova. Requereu o acolhimento da preliminar de impugnação do valor da causa. Pediu a improcedência da ação. Juntou documentos.

Houve réplica - Evento14.

Foi afastada a preliminar de impugnação ao valor da causa - Evento 16.

Intimadas, ambas as partes requereram a realização de perícia - Eventos 20-21.

Foi deferida a perícia - Evento 23.

Sobreveio a informação do óbito do autor e requerimento do julgamento do mérito da ação - Evento 28

Foi requerida a substituição processual para que passe a constar passando a figurar no polo ativo o ESPÓLIO DE DANIEL SCHARDONG - Evento 45.

Foi determinada a retificação da autuação para constar no polo ativo o ESPÓLIO DE DANIEL SCHARDONG - Evento 49.

Foi realizada perícia de forma indireta -Evento 77.

Com vista, as partes se manifestaram - Eventos 81 e 82.

O Ministério Público opinou pela procedência da ação - Evento 88.

Encerrada a instrução, as partes apresentaram memoriais escritos - Eventos 94 e 95.

Relatei. Decido.

A pretensão da parte autora é de que a ré seja obrigada a fornecer o medicamentos Brentuximabe Vedotina - 5 frascos/cxa de 50mg; Nivolumab - 2 frascos de 100mg; e Nivolumab - 1 frasco de 40mg, por ser portador de Linfoma não-Hodgkin difuso (CID C83), conforme indicado pelo médico assistente -Evento 1, OUT7.

Diante da concessão da tutela antecipada e considerando que o autor faleceu no curso da ação, prospera a pretensão da parte autora para que seja julgado o mérito da presente ação.

A demandada, por sua vez, referiu que o plano de saúde da autora exclui expressamente da relação negocial e da cobertura securitária o custeio de tratamentos off-label - Cláusula 9ª, III.

Gize-se que os contratos de planos de saúde estão submetidos às normas do Código de Defesa do Consumidor. Inclusive, pacificando tal orientação no egrégio STJ, foi editada a Súmula 469, com o seguinte teor:

Súmula 469. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde.

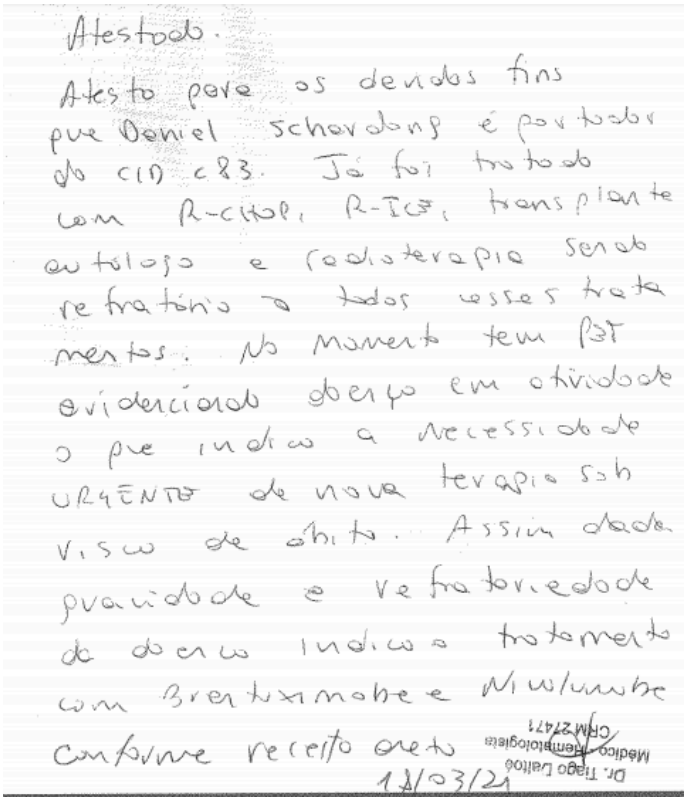
Nestas circunstâncias, o art. 47, do CDC, determina que as cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor.

Igualmente, deve incidir o disposto no art.51, IV, §1°, II, do CDC, segundo o qual é nula a cláusula que estabeleça obrigações consideradas iníquas, que coloquem o consumidor em desvantagem. Considera-se também exagerada a cláusula que restringe direitos ou obrigações inerentes à natureza do contrato, ameaçando seu objeto e equilíbrio, ou ainda que seja excessivamente onerosa ao consumidor.

De outro lado, os planos de saúde apenas podem estabelecer para quais moléstias oferecerão cobertura, não lhes cabendo limitar o tipo de tratamento que será prescrito, incumbência essa que pertence ao profissional da medicina que assiste o paciente.

Além do mais, vale dizer que deve ser priorizado o direito à saúde e à vida em relação ao direito contratual.

De acordo com o laudo médico, Dr. Tiago Daltoé (Evento 1, OUT7, fl.2), o autor é portador do CID C83, já foi tratado com R-CHOP, R-ICE, transplante eutólogo e radioterapia, refratário a todos os tratamentos. Alegou a necessidade de nova terapia sob risco de vida, indicando o uso de Brentuximabe Vedotina - 5 frascos/cxa de 50mg; Nivolumab - 2 frascos de 100mg; e Nivolumab - 1 frasco de 40mg.


Atestado.
Atesto para os devidos fins que Daniel Schardong é portador do CID C83. Já foi tratado com R-CHOP, R-ICE, transplante autólogo e radioterapia sendo refratário a todos esses tratamentos. No momento tem PET evidenciando doença em atividade o que indica a necessidade URGENTE de nova terapia sob risco de óbito. Assim dada gravidade e refratariedade da doença indico o tratamento com Brentuximabe e Nivolumabe conforme receituário anexo
13/03/21
Dr. Tiago Daltoé
Médico Hematologista
CRM 27471

De acordo com o documento do Evento 1, OUT21, a ré negou a cobertura dos medicamento, sob o argumento que o contrato possui cobertura somente os procedimentos, medicações e exames complementares indicados no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS.

A autora é beneficiária do plano "UNIPART MAIS COLETIVO EMPRESARIAL" - Evento 1, OUT20, o qual prevê a exclusão de cobertura dos procedimentos não constantes expressamente no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde editado pela ANS - Evento 17, CONTR2, :

DOS SERVIÇOS NÃO COBERTOS

Cláusula 10ª: Estão expressamente excluídos das coberturas previstas neste contrato os seguintes serviços:

I. **consultas, exames diagnósticos e todos os procedimentos médicos decorrentes de acidentes de trabalho;**
II. **exames admissionais, demissionais e periódicos e todos os procedimentos relativos à medicina ocupacional;**
III. **tratamento clínico ou cirúrgico experimental: é aquele que emprega fármacos, vacinas, testes e diagnóstico, aparelhos ou técnicas cuja segurança, eficácia e esquema de utilização ainda sejam objeto de pesquisas em fase I, II ou III, ou que utilizem medicamentos ou produtos para a saúde não registrados no país, bem como aqueles considerados experimentais pelo Conselho Federal de Medicina – CFM, ou o tratamento a base de medicamentos com indicações que não constem da bula registrada na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA);**

XXX. procedimentos e exames que não estejam expressamente previstos no Rol de Procedimentos Médicos da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS vigente na data da assinatura deste contrato.

Realizada a perícia indireta, respondeu o Expert - Evento 59, DESPADEC1:

9. Há recomendação na literatura médica para o uso de Brentuximabe e Nivolumab, no tratamento de Linfoma Não Hodgkin de Grandes Células B, Primário de Mediastino?

Sim. Na falha dos tratamento que o autor realizou.

10. Qual é o nível de evidência e em que fase se encontram os referidos estudos?

Fase I. Nivel baixo de evidencia.

11. O tratamento com Brentuximabe e Nivolumab enquadra-se no conceito de tratamento experimental?

Sim. Pois somente tem estudos fase I, com baixo nível de evidencia.

Ao final, concluiu o Perito:

9 - CONCLUSÃO: Parte autora acometida por Linfoma não-Hodgkin difuso (CID C83) desde 08/07/2019, tendo efetuado o tratamento com R-CHOP, R-ICE, transplante autólogo e radioterapia sendo refratório a todos os tratamentos, demonstrando a agressividade de sua doença mesmo com todo o tratamento imposto. Foi indicado como última alternativa a medicação pleiteada, por ser a única opção viável nesse cenário desesperador e sem esperança para o autor. Devido ao baixo número de paciente na situação do autor no mundo não há estudos robustos e com grau de evidencia suficiente que o Rol da ANS exige, sendo considerado então um tratamento experimental ou off-label. A parte autora faleceu em decorrência de infecção oportunista devido a baixa imunidade de base que sua doença acarreta. Atualmente, existem poucos estudos que avaliam a eficácia da medicação pretendida para o tratamento do LH. Além disso, ainda não foram realizados Ensaios Clínicos Randomizados (ECR) para avaliar esse medicamento nessa condição de saúde. **Os estudos realizados demonstraram eficácia e efetividade satisfatórias para o LH recidivante ou refratários aos tratamentos anteriores. No entanto, os estudos disponíveis são ensaios clínicos de fase I e II, com pequeno tamanho amostral, sem uso de comparadores e não randomizados.** Os estudos do tipo coortes retrospectivas realizados também possuíam pequeno tamanho amostral e não utilizaram comparadores. **Portanto, a evidência disponível sobre a efetividade da medicação pretendida para o tratamento de LH possui baixa a moderada qualidade.** As evidências sobre a segurança também possuem baixa a moderada qualidade. [Grifei].

Consoante a Lei n. 14.454, que alterou a lei 9.656/1998, editada em 21-9-2022, indica que o rol da ANS constitui referência básica no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, ou seja, é meramente exemplificativo.

"[...]
§ 12. O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, atualizado pela ANS a cada nova incorporação, constitui a referência básica para os planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1º de janeiro de 1999 e para os contratos adaptados a esta Lei e fixa as diretrizes de atenção à saúde.
§ 13. Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que:
I – exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou
II – existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais."

Oportuno esclarecer que a limitação do critério médico na escolha de procedimento para o tratamento da doença é vedada expressamente pelo art. 16 do Código de Ética Médica, *in verbis:*

"Nenhuma disposição estatutária ou regimental de hospital, ou instituição pública, ou privada poderá limitar a escolha, por parte do médico, dos meios a serem postos em prática para o estabelecimento do diagnóstico e para a execução do tratamento, salvo quando em benefício do paciente".

Dessa forma, cabe ao médico assistente, o qual é conhecedor do quadro clínico, determinar qual o tipo de tratamento mais adequado ao caso, prescrever os métodos e os procedimentos mais indicados para o paciente, bem como os materiais e medicamentos que deverão ser utilizados.

Ou seja, é vedado ao plano de saúde insurgir-se contra as determinações do médico quanto aos medicamentos e materiais utilizados no procedimento e que objetivam reduzir os riscos do paciente e, em consequência, os custos do plano de saúde, desde que comprovada a eficácia à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico, ou, ainda, que haja recomendação pela Conitec ou de órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais.

Possuindo o contrato firmado pelas partes cobertura de tratamento para a moléstia apresentada pela parte autora, como no caso da presente demanda, não pode o plano, agora, negar-se a arcar com as despesas do medicamento indicado pelo médico do paciente, alegando a exclusão da cobertura de tratamentos *off label*, uma vez que preenchido todos os outros requisitos, quais sejam: cobertura para moléstia apresentada; e exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico.

Assim, havendo cobertura contratual para a moléstia apresentada pela parte autora e estando o medicamento indicado pelo médico assistente registrado na ANVISA, incumbe ao plano de saúde demandado fornecer o medicamento prescrito, restando superada a questão da taxatividade do rol da ANS, nos termos da Lei n. 14.454/2022.

Nesse sentido, é o posicionamento do TJ/RS:

> APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. *PLANO* DE *SAÚDE*. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. **APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. O FATO DE A MEDICAÇÃO SER "*OFF LABEL*", OU SEJA, EMPREGADA PARA USO CUJA INDICAÇÃO NÃO ESTÁ NA BULA, NÃO CONSTITUI ÓBICE AO SEU FORNECIMENTO PELA OPERADORA DO *PLANO* DE *SAÚDE*. É ABUSIVA A NEGATIVA DE COBERTURA DE *PLANO* DE *SAÚDE* QUANDO A DOENÇA DO PACIENTE NÃO CONSTAR NA BULA DO MEDICAMENTO PRESCRITO PELO MÉDICO QUE MINISTRA O *TRATAMENTO* (USO "*OFF-LABEL*")** (AGINT NO ARESP 1.713.784/SP, RELATOR MINISTRO RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, JULGADO EM 15/3/2021, DJE 7/4/2021). APELO NÃO PROVIDO.(Apelação Cível, Nº 50043178420208210004, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ney Wiedemann Neto, Julgado em: 27-10-2022). [Grifei].

Logo, tenho por evidenciada a responsabilidade do plano de saúde demandado pela cobertura do tratamento prescrito pela médica assistente à autora, devendo arcar com os valores do medicamentos Brentuximabe Vedotina - 5 frascos/cxa de 50mg; Nivolumab - 2 frascos de 100mg; e Nivolumab - 1 frasco de 40mg, até a data do óbito do autor, em 10-01-2022 - Evento 28, CERTOBT2.

Isso posto, **JULGO PROCEDENTE** a presente ação proposta por **DANIEL SCHARDON** contra **UNIMED NORDESTE RS SOCIEDADE COOP DE SERV MEDICOS LTDA.**, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para tornar definitiva a tutela antecipada, condenando a ré à cobertura integral do tratamento indicado ao autora - Brentuximabe Vedotina - 5 frascos/cxa de 50mg; Nivolumab - 2 frascos de 100mg; e Nivolumab - 1 frasco de 40mg, até a data do óbito do autor, em 10-01-2022 - Evento 28, CERTOBT2, com custeio das despesas pelo respectivo plano de saúde.

Pelo princípio da sucumbência, imponho à demandada o pagamento das despesas processuais, mais honorários ao procurador da parte autora, que fixo em R$3.000,00, a ser corrigido pelo IGP-M a contar desta sentença e juros de mora de 1% ao mês a contar do trânsito em julgado, observado o singelo desenrolar da causa e demais critérios do art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC.

Intimem-se. Havendo recurso, após processado, remetam-se ao TJRS. Caso contrário, arquivem-se.

Documento assinado eletronicamente por **JOAO PAULO BERNSTEIN, Juiz de Direito**, em 16/11/2022, às 10:59:0, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://eproc1g.tjrs.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, informando o código verificador **10028656100v19** e o código CRC **3fa643e8**.